

1500930-44.2022.8.26.0269

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Alfredo Gehring Cardoso Falchi Fonseca

Comarca: Itapetininga

Foro: Foro de Itapetininga

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/07/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUIS HENRIQUE ARAUJO ALVES

Data da Audiência:

27/07/2022

Iniciados os trabalhos por videoconferência, com concordância das partes (inclusive do réu), verificou-se a presença do Exmo. Sr. Dr. Alfredo Gehring Cardoso Falchi Fonseca, MM. Juiz de Direito da Segunda Vara Criminal de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itapetininga

Foro de Itapetininga

2ª Vara Criminal

Avenida Peixoto Gomide, centro, Itapetininga - SP - cep 18200-160

TERMO DE AUDIÊNCIA - VIDEOCONFERÊNCIA

Processo nº:

1500930-44.2022.8.26.0269 - Controle 2022/000692

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUIS HENRIQUE ARAUJO ALVES

Data da Audiência:

27/07/2022

Iniciados os trabalhos por videoconferência, com concordância das partes (inclusive do réu), verificou-se a presença do Exmo. Sr. Dr. Alfredo Gehring Cardoso Falchi Fonseca, MM. Juiz de Direito da Segunda Vara Criminal de Itapetininga, dos representantes do Ministério Público e da Defensoria Pública, e do Acusado Luis Henrique Araújo Alves. Na "sala virtual" permaneceram exclusivamente o Defensor e seu representado para contato prévio. Antes de serem inquiridas as testemunhas foram devidamente advertidas acerca da incomunicabilidade. Foram ouvidas as testemunhas Rafael Clemente Santos e Edmilson Jensen Leandro arroladas pelas partes. Em seguida o réu foi interrogado. Os depoimentos foram registrados pelo sistema Microsoft Teams. Pelas partes foi dito que não tinham diligências a requerer. Pelo(a) MM^(a). Juiz(a) foi dito que: Não havendo mais provas a serem colhidas, declaro encerrada a instrução, determino as partes que passem aos debates. Dada a palavra ao Dr. Promotor de Justiça, foi dito: MM. Juiz, acha-se processado o acusado como incurso no artigo 33 c.c. 40, inciso III, ambos da Lei de Tóxicos, em face dos fatos detalhadamente narrados na denúncia. Concluída a instrução, a ação penal merece proceder. A materialidade delitiva encontra respaldo no laudo de exame químico-toxicológico acostado aos autos. Autoria e existência delitiva, ao seu turno, vêm comprovadas nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório. Ouvido nos autos, tanto em juízo como em solo judicial, os agentes

de segurança penitenciária narraram sobre o encontro das drogas no interior de um banheiro da ala B, sendo certo que ao ingressarem notaram o acusado com um pote tipo tupperware, sendo que instado a respeito informou que ali tinha maconha, pelo que foram apreendidos os invólucros e adotadas as providências. As palavras dos agentes revestem-se de imensurável valor probatório, uma vez que isentas e desprovidas de qualquer intenção de prejudicar o agente. Demais disso, não há nenhum elemento capaz de indicar uma suposta suspeição do agente público; ao contrário, revela de forma absolutamente convincente toda a dinâmica da diligência que resultou na apreensão do entorpecente na penitenciária. Dessa forma, patente a conduta atribuída ao réu, sendo certo que a quantidade da droga que possuía e a forma como estava acondicionada, indica claramente que se destinava, sim, a ulterior entrega ao consumo de outros detentos, tanto é que o próprio acusado, nas oportunidades em que ouvido a respeito, apresentou versões contraditórias, mas jamais foi capaz de refutar que a droga era a ele destinada. Portanto, demonstradas autoria e materialidade, pugna a Justiça Pública pela procedência da ação penal, condenando-se o acusado nos termos da denúncia. Não se apresenta cabível a aplicação do redutor ao tráfico, haja vista a incidência da causa de aumento decorrente da prática do crime no interior do instituo prisional, devendo, outrossim, ser a pena base fixada acima do patamar mínimo, pois o acusado é reincidente, devendo, na mesma toada, ser fixado regime inicial fechado para o débito da sanção carcerária. Dada a palavra ao Dr. Defensor, foi dito: MM. Juiz: O acusado foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33 c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06. Ocorre que a pretensão acusatória não merece prosperar, visto que as provas levadas aos autos não autorizam a prolação de um édito desfavorável ao acusado. I. DA NECESSÁRIA ABSOLVIÇÃO DO RÉU. Ausência de provas de que os entorpecentes pertenciam ao acusado. Local com circulação de outros presos. Como se sabe, a Constituição Federal garante a presunção de inocência, de tal sorte que se faz mister um conjunto probatório robusto e harmônico para que se autorize a prolação de um édito condenatório. Não é, todavia, o que ocorre na hipótese dos autos. Os agentes penitenciários ouvidos narraram, apenas, circunstâncias da apreensão do objeto e narraram que o local se tratava de um banheiro, em que diversos presos circulavam. Ainda, declararam que no dia da abordagem havia mais presos no local. Não fizeram qualquer menção sobre terem visto o réu na posse de drogas em dias anteriores ou de já terem visualizado o réu comercializando drogas no presídio. O réu negou que tivesse ciência de que havia entorpecentes no local. Reiterou integralmente o depoimento prestado na própria penitenciária quando ouvido em declarações. Ou seja, não há absolutamente nada que indique a prática delitiva por parte do acusado: não há como afirmar que ele soubesse que ali havia entorpecentes e, ademais, como o local se tratava de um banheiro, coletivo, com acesso livre por diversos presos, o entorpecente poderia pertencer a qualquer pessoa. Não há como imputar o delito ao acusado tão somente pelo fato de estar no local, sendo que não há provas de que ele tivesse ciência da existência droga. Por outro lado, ainda que se considere crível que o réu estivesse com o objeto nas mãos, não há como afirmar que o entorpecente lhe pertencia e se destinava a terceiros. A acusação não se desincumbiu o ônus de comprovar os fatos que alega. Tais situações colocam em dúvida a versão apresentada. Diante disso, é o caso de absolvição do réu nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal. 2. DA DESCLASSIFICAÇÃO: Subsidiariamente, como a acusação se baseia, tão somente, em apreensão de diminuta quantidade de entorpecentes e como o réu não foi preso entregando ou vendendo algo para terceiros, mas apenas na posse de pequena quantidade de entorpecente, a conduta mencionada melhor se adequa àquela prevista no art. 28 da lei de drogas. A distinção do tipo legal do artigo 28 da Lei n. 11.343 do tipo penal do art. 33 da mesma lei se dá por força do elemento subjetivo específico "para consumo pessoal". Conquanto o tipo do art. 28 contenha mais elementos subjetivos, não cabe à Defesa provar esse fim específico, mas sim cabe ao acusador demonstrar que esse fim não existia; e isto por força do princípio da presunção de inocência e da fórmula do in dubio pro reo, que determinam que se presuma que o acusado incorreu no tipo penal menos grave enquanto o conjunto probatório não indicar seguramente no sentido contrário. Desta maneira, diante da

ausência de evidências de que o réu visasse comercializar e obter lucro (circunstância inerente ao tipo do art. 33 da Lei nº 11.343/06) deve prevalecer o entendimento de que a classificação jurídica correta para a conduta atribuída a ele é a do artigo 28, da Lei nº 11.343/06, devendo-se operar, portanto, a desclassificação, com suas consequências legais. 3. TESES

SUBSIDIÁRIAS: Subsidiariamente, em caso de eventual condenação, requer-se: a) a fixação da pena-base do acusado no patamar mínimo legal; b) seja fixado regime inicial semiaberto, mesmo que, frise-se, se trate do crime de tráfico, em conformidade com o entendimento já sumulado pelo Supremo Tribunal Federal (Súmulas nº 718 e 719) e pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula nº 440), bem como considerando o reconhecimento da inconstitucionalidade do art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, que impunha, obrigatoriamente, o início do cumprimento da pena no regime fechado, em relação aos crimes hediondos e os a ele equiparados (STF - Pleno - HC nº 111.840/ES - rel. Min. Dias Toffoli), observando-se, ainda, o disposto no artigo 387, § 2º, do CPP; c) o afastamento da causa de aumento de pena pleiteada, visto que não basta que o delito aconteça no interior do presídio, sendo necessário comprovar que o acusado pretendia efetivar comércio de drogas voltado ao sistema penitenciário, o que não ocorreu no caso; d) a possibilidade de o acusado apelar em liberdade, nos moldes do que estabelece o artigo 8, item 2, alínea "h", da Convenção Americana sobre Direitos Humanos - Pacto de San José de Costa Rica. Na sequência, pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte sentença: Vistos. LUIS HENRIQUE ARAÚJO ALVES, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", c.c. o artigo 40, inc. III, da Lei n. 11.343/2006, porque, em 23 de setembro de 2021, por volta das 14 h, nas dependências do Centro de Ressocialização de Itapetininga, situado à Rodovia Gladys Bernardes Minhoto, km 63, no Bairro Capão Alto, nesta Cidade e Comarca, foi surpreendido ao trazer consigo, para fins de comércio, trinta e oito porções da substância conhecida por "maconha", com peso de 52,32 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal/regulamentar. Notificado, fls. 44, o Réu apresentou defesa preliminar, fls. 48/49. A denúncia foi recebida, fls. 50/51, e o Réu, citado, fls. 74. Durante a instrução, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes, seguindo-se o interrogatório do Acusado (gravação por videoconferência). Em alegações finais o Dr. Promotor de Justiça pediu a condenação do Réu, nos exatos termos da denúncia; por outro lado, a Dra. Defensora insistiu na absolvição e, de forma subsidiária, na desclassificação. É o relatório. I - FUNDAMENTO. A pretensão é procedente. Às fls. 08 foi juntado o Auto de Exibição e Apreensão no qual consta: trinta e oito porções de maconha, com peso de 61,13 gramas. Às fls. 09/12 foi juntado o Laudo Pericial de Exame Definitivo de Entorpecente n. 322.097/2021 no qual consignou: "Do resultado. Utilizando-se metodologias adequadas para análise do referido material, foi detectada a presença da substância Tetrahydrocannabinol (THC), constante na lista F2: Lista de Substâncias Psicotrópicas - Lista das Substâncias de uso Proscrito no Brasil da portaria SVS/MS 344/1998 e atualizações posteriores". Rafael Clemente Santos, agente penitenciário, disse que entrou no banheiro para vistoria e cada preso foi sendo revistado e na sequência, liberado; o Réu percebeu a ação e tentou sair, mas Edimilson o parou, perguntou o que e ele tinha e lhe foi respondido "maconha, senhor!". Edimilson Jensen Leandro, agente penitenciário, disse

que entrou no banheiro, o Réu tentou sair, mas foi parado, ele carregava consigo porções de "maconha". Luís Henrique Araújo Alves, Réu, ao ser interrogado, disse que tinha ido ao banheiro de uso coletivo, tinha outros presos, os quais começaram a sair; os agentes entraram, viram uma saboneteira, desconhecida pelo Acusado, e eles perguntaram o que tinha dentro dela, o que o Réu afirmou desconhecer. Depois o conduziram, mas desconhecia a droga. Com efeito, analisando-se a prova colhida infere-se a prática de tráfico de entorpecentes, pois, apesar da negativa do Réu, ele, ao perceber a ação dos agentes, na posse de um recipiente com porções de "maconha", tentou sair do local e, dessa forma, elidir a ação dos agentes. Provada a propriedade, a finalidade mercantil é evidente, pois não é crível que o Réu fosse consumir trinta e oito porções da substância conhecida por "maconha", com peso de 52,32 gramas, naquela oportunidade; ademais, a forma de embalagem da substância demonstra a intensão de distribuí-la, notadamente em local em que o Réu teria

contato com presos de outras alas, ou seja, pessoas que não eram de seu cotidiano, portanto pessoas ávidas pela aquisição da droga naquela oportunidade. O fato do Réu não ter sido flagrado em outras oportunidades na distribuição das drogas em nada corrói a prova produzida pela Acusação. Não há razão para desprezar a prova acusatória porque as testemunhas relataram detalhes a respeito da abordagem, localização e apreensão do entorpecente. As testemunhas não tem motivos para incriminar um inocente. Não se conhece razão plausível para que as testemunhas arquivetasse um diabólico plano visando incriminar este Réu, apontando-o como autor dessa espécie de crime. Tudo indica que as testemunhas agiram com lisura e, por certo, não se poderia desacreditar os seus relatos, uma vez que apenas tais pessoas é que presenciaram e participaram da diligência de localização da droga, não se podendo entender como suspeitos. Portanto, de acordo com o examinado, está comprovado que o Réu trazia consigo substâncias entorpecentes, conduta esta que configura a consumação do delito de tráfico de entorpecente, pois, para a configuração do crime previsto no "caput", do art. 33, da Lei nº 11.343/06, de ação múltipla ou conteúdo variado, basta que o agente realize qualquer das condutas descritas no tipo penal que, "in casu", foi a de trazer consigo, ilegalmente, substância entorpecente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Evidente o dolo direto do agente, isto é, a vontade livre e consciente de praticar a conduta descrita no tipo do art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06. Destarte, a pretensão procede. II - DA DOSIMETRIA DA PENA. (Art. 59, inc. II, do Código Penal). Fixada a responsabilidade do Acusado, passo à dosimetria da pena. - Art. 59, "caput", do Código Penal: As circunstâncias judiciais são favoráveis, assim fixo a pena em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias - multa, no piso. - Art. 61 e Art. 65, ambos do Código Penal: O Réu é reincidente, fls. 28 (Proc. 809-60.2015), esta específica, e fls. 29 (Proc. 660-88.2020), razão pela qual majoro a pena em 1/5, que passa nesta fase a 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias - multa, no piso. ART. 68: Incabível a causa de diminuição de pena prevista no § 4º, do art. 33, da Lei de Entorpecentes, pois o Réu é reincidente específico. Presente a causa de aumento de pena do inc. III, do art. 40, da Lei nº. 11.343/2006, pois o delito foi praticado em estabelecimento prisional, e, assim, a pena passa, nesta fase, a 07 (sete) anos de reclusão e de 700 (setecentos) dias - multa. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA - ART. 59, INC. III, DO CÓDIGO PENAL: Em razão da reincidência específica, o Réu deverá cumprir a pena no regime inicial fechado. - Art. 59, inc. IV, c/c Art. 44, do Código Penal: Considerando-se a pena aplicada, o Réu não faz jus à substituição. - Art. 77, do Código Penal: Considerando-se a pena aplicada, o Réu não faz jus ao sursis. III - DECIDO. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia e o faço para condenar LUIS HENRIQUE ARAÚJO ALVES, qualificado nos autos, a pena de 07 (sete) anos de reclusão, no regime inicial fechado, e de 700 (setecentos) dias - multa, no piso, sendo o valor unitário de cada dia-multa de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo da conduta, por incidir no art. 33, "caput", c/c o art. 40, inc. III, da Lei nº. 11.343/2006. Sem condenação nas custas, em virtude de ser representado pela Defensoria Pública. O Réu respondeu em liberdade ao processo, e, insubsistentes as razões da prisão preventiva, poderá aguardar nessa condição o desfecho de eventual recurso. Sentença publicada em audiência. Cumpra-se. A presente audiência foi realizada excepcionalmente por meio virtual, diante da Pandemia do COVID-19. O Termo de Audiência ficará disponível no sistema SAJ, ficando os presentes intimados do prazo de 5 (cinco) dias para interposição do recurso da sentença, dispensada a assinatura das partes, por se tratar de processo digital - sistema SAJ (Artigo 1.269 das NSCGJ). Nada Mais. Itapetininga, 27 de julho de 2022. Eu, (Marina Alice Correa de Almeida), Escrevente Técnico Judiciário digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA